

1500489-69.2022.8.26.0073

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

Comarca: Avaré

Foro: Foro de Avaré

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/10/2022

... pág. 209/210).

No mesmo sentido a jurisprudência:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROVA BASTANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO AFASTADA DE OFÍCIO COM EXTENSÃO AO CO-RÉU - APELAÇÃO DESPROVIDA. Para a existência do crime de tráfico basta a guarda da substância entorpecente, não sendo exigível a prova da efetiva venda da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Avaré

Foro de Avaré

1ª Vara Criminal

Rua Abílio Garcia, 527, Avare-SP - cep 18706-047

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500489-69.2022.8.26.0073 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500489-69.2022.8.26.0073

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Inquérito Policial - 2057481/2022 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 23314655 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2057481 - DEL.SEC.AVARE PLANTÃO, 2057481 - DISE- DEL.SEC.AVARE, 013/2022 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Avaré

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNO BRAZ JOVENIL e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LEONARDO LABRIOLA FERREIRA MENINO

VISTOS.

BRUNO BRAZ JOVENIL e EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA VALENTIM, já qualificados nos autos, foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nas sanções dos artigos 33, "caput", e 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, sob a acusação de que, em dia e horário indeterminado, porém anterior à noite de 1º de março de 2022, por volta das 23 horas, na Rua Diamantino Armando, número 137, neste município e comarca de Avaré, os réus associaram-se com o fim de praticar, reiteradamente ou não, o delito previsto no artigo 33 da Lei 11343/06. Consta, ainda, dos autos que na noite de 1º

de março de 2022, por volta das 23 horas, na Rua Diamantino Armando, número 137, neste município e comarca de Avaré, os réus acima qualificados traziam consigo 50 (cinquenta) porções de cocaína (crack), com peso aproximado de 1077,81 (um mil e setenta e sete gramas e oitenta e um centigramas) e 01 (uma) porção de maconha, com peso total aproximado de 42,38g (quarenta e dois gramas e trezentos e oitenta miligramas), conforme laudo de exame químico-toxicológico a fls. 188/193, substância que causa dependência, o que faziam em desacordo com norma legal ou regulamentar (portaria 344/98 SVS/MS).

Auto de prisão em flagrante e demais peças do inquérito policial a fls. 01/210. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva a fls. 128/132. Mandados de prisão cumpridos a fls. 177/183. A denúncia foi oferecida em 10 de março de 2022 e os réus, devidamente notificados a fls. 335/336, apresentaram Defesa Prévia a fls. 365. Não sendo o caso de absolvição sumária, a denúncia foi recebida em 27 de maio de 2022, ocasião em que também foi designada audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 366/369). Em audiência, foram inquiridas 02 testemunhas de acusação e os réus interrogados (fls. 459/460 e gravações audiovisuais). Em sede de alegações finais, o Ministério Público postulou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia (fls. 467/473). A Defesa do réu Eduardo pleiteou, preliminarmente, pelo reconhecimento da nulidade da busca e apreensão e consequente absolvição do réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, CPP. Subsidiariamente, requereu a absolvição ante a ausência de provas com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP e/ou a desclassificação do crime de tráfico para uso de drogas (fls. 475/504). A ilustre defesa do corréu Bruno, igualmente, pugnou em sede preliminar pela nulidade da busca pessoal e absolvição do réu. Subsidiariamente, em caso de condenação, pleiteou pela fixação da pena em seu patamar mínimo legal e pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 508/518).

É, sucinto o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Segundo a inicial acusatória, "em dia e horário indeterminado, porém anterior à data da abordagem, BRUNO e EDUARDO associaram-se com o fim de praticar o tráfico de drogas. Para tanto, EDUARDO incumbiu BRUNO de vender as drogas de sua propriedade, de sorte que o último permanecia no ponto de tráfico. Na data dos fatos, BRUNO trazia consigo uma sacola contendo quarenta e nove porções de cocaína, ocasião em que foi surpreendido pela Polícia Militar durante patrulhamento. Na ocasião, BRUNO narrou que a droga era de EDUARDO, pessoa conhecida pela prática do tráfico de drogas, o qual havia estado no local pouco tempo antes da chegada dos policiais militares. Os agentes estatais empreenderam diligências nas imediações e localizaram EDUARDO na via pública. Constatou-se que o denunciado trazia consigo um tijolo de cocaína no interior de uma sacola. Em diligência à residência de EDUARDO foi localizada, ainda, uma porção de maconha. A quantidade de droga apreendida, sua forma de acondicionamento e as circunstâncias da prisão indicam que os entorpecentes se destinavam ao fornecimento e entrega ao consumo de terceiro, estando os ora denunciados associados para tal finalidade".

De prôemio, a preliminar de nulidade de provas alegada pelas Defesas dos réus não merece prosperar. Não se vislumbra o alegado vício apontado pela combativa defesa, no tocante à obtenção de prova ilícita em decorrência da revista pessoal e domiciliar não autorizada. Sustenta a d. defesa que a absolvição seria de rigor, eis que todas as provas dos autos eivariam de realização de revista pessoal e domiciliar ilícita e irregular, e por tal razão deveriam ser afastadas todas as provas dela decorrentes, porquanto os acusados, em nenhum momento, consentiram para a busca pessoal e/ou domiciliar pelos policiais militares, vício que, à evidência, não restou caracterizado. Isso porque, por imperativo constitucional, "...às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, exceto as militares" (art. 144, §4º, da CF).

Desse modo, ante a prática diuturna dos policiais no combate ao crime, estes são capazes de identificar pessoas em atitude suspeita v.g. nervosismo ao visualizar a viatura, tentativa de fuga, presença em locais conhecidos nos meios policiais pela prática de delitos etc. circunstâncias que, por obviedade plena, não seriam

detectadas por leigos. Não é por outro motivo que o Código de Processo Penal expressamente prevê, no artigo 244, que “A busca pessoal independe de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.

Ademais, a busca pessoal, no caso de existir fundada suspeita, como havia no caso sob exame, dispensa autorização judicial, conforme previsão do § 2º do artigo 240 do CPP, porque a diligência policial era necessária para elucidação dos fatos a investigar. Além disso, o crime de tráfico de entorpecentes é classificado como permanente, posto que enquanto um dos verbos núcleos está sendo executado, a lesão ao bem jurídico é renovada no tempo, o que permite a prisão em flagrante. Ciente de que o acusado trazia consigo droga na via pública, a atuação dos agentes policiais se mostrou providência necessária. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE PELA GUARDA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. ART. 301 DO CPP. BUSCA PESSOAL EFETUADA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. (...) 3. A teor do art. 244 do CPP, a busca pessoal justifica-se quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Na espécie, a busca policial se deu de forma legal, tendo em vista a existência de fundada suspeita de que o paciente estaria transportando droga em seu veículo. No caso, ao receberem a notícia de que o paciente fazia o transporte de drogas em seu veículo, os guardas municipais primeiro identificaram o referido automóvel e fizeram sinal de parada, o réu se negou a parar e tentou fugir, gerando a suspeita da prática de crime, o que justificou a abordagem. Na sequência, ao finalmente parar o carro, o réu saiu dizendo "ladrão", "perdi". Além disso, o veículo possuía cheiro de entorpecente. Tudo isso, motivou a busca veicular, a apreensão do entorpecente e a prisão em flagrante. 4. Agravo Regimental improvido. (AgRg no HC 635.303/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021 (destaquei))

Além disso, a entrada dos policiais na residência do réu não ocorreu de forma irregular, tampouco o flagrante foi ilegal não havendo, pois, se falar em irregularidade e/ou nulidade.

A Constituição Federal expressamente autoriza a busca domiciliar sem mandado judicial em casos excepcionais, sendo uma destas hipóteses a ocorrência de flagrante delito (Artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (sem destaques no original). Por tal, e porquanto o crime de tráfico de drogas ser permanente, havia situação flagrancial, circunstância que legitimou o ingresso dos policiais na residência do réu. Nesse sentido, já se posicionou o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Apelação Criminal -Tráfico de entorpecente- Nulidade do processo e da prova coligida porque a busca domiciliar fez-se sem autorização judicial -Inexistência Tráfico de entorpecente na modalidade “ter em depósito” é crime permanente - A ocorrência de flagrante delito justifica a busca domiciliar sem autorização judicial -Tipificação- A prova oral, a quantidade e a variedade de forma do entorpecente apreendido em poder dos réus asseguram que a droga se destinava à venda . Consumação .Para a consumação do crime do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, de ação múltipla, é desnecessário surpreender o agente em ato de mercancia, bastando que haja conduta que se ajuste a um dos verbos do tipo penal (misto alternativo Ausência de elementos seguros a indicar que os acusados estivessem associados para traficar Liame subjetivo de caráter estável não caracterizado Recursos desprovidos” (Apelação Criminal n.º 990.08.160355-1 rel. Desembargador José Raul Gavião de Almeida) (g.n.).

Ora, o ingresso dos policiais na residência, sem autorização judicial, não está eivado por qualquer mácula. Primeiramente, porque não há comprovação de que a entrada não foi permitida. De fato, não há qualquer menção nos autos de resistência

ao ingresso dos agentes por parte dos residentes.

Em adição, o artigo 5º, XI, da Constituição Federal prevê que a busca domiciliar não prescinde de mandado judicial, salvo nas hipóteses excepcionais, constitucionalmente previstas, dentre elas o caso de flagrante delito. Como é cediço, o ato análogo ao tráfico de entorpecentes é crime permanente e, em caso de flagrante de crime dessa natureza é possível a realização de busca domiciliar sem mandado judicial.

Assim, era perfeitamente lícito aos policiais, incumbidos do combate à criminalidade, adentrar na casa onde a droga estava. Não se pode cogitar, por conseguinte, na ilicitude das provas obtidas, pois o momento consumativo do delito de traficância se prolonga no tempo. A respeito da prescindibilidade do mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, há sedimentada jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal: "A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (RE nº 603.616/TO; Relator Ministro Gilmar Mendes). Nesse sentido, já se posicionou o Tribunal de Justiça de São Paulo:

"Apelação Criminal -Tráfico de entorpecente- Nulidade do processo e da prova coligida porque a busca domiciliar fez-se sem autorização judicial -Inexistência Tráfico de entorpecente na modalidade "ter em depósito" é crime permanente - A ocorrência de flagrante delito justifica a busca domiciliar sem autorização judicial -Tipificação- A prova oral, a quantidade e a variedade de forma do entorpecente apreendido em poder dos réus asseguram que a droga se destinava à venda . Consumo .Para a consumação do crime do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, de ação múltipla, é desnecessário surpreender o agente em ato de mercancia, bastando que haja conduta que se ajuste a um dos verbos do tipo penal (misto alternativo Ausência de elementos seguros a indicar que os acusados estivessem associados para traficar Liame subjetivo de caráter estável não caracterizado Recursos desprovidos" (Apelação Criminal n.º 990.08.160355-1 rel. Desembargador José Raul Gavião de Almeida) (g.n.).

Ora, finda a instrução processual, restou claro que a abordagem foi motivada pela suspeita de traficância.

Inquestionável que a ação dos agentes da lei se revestiu de fundada suspeita, em conformidade com o artigo 240, § 2º, do Código de Processo Penal, sendo descabida a aventada ilegalidade da busca pessoal.

Superada a preliminar, no mérito, a ação merece ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 11/14), auto de exibição e apreensão a fls. 15/16, laudo de constatação provisória a fls. 76/82, fotografias de fls. 83/92, laudo de exame químico-toxicológico a fls. 188/193, bem como por toda prova oral produzida em juízo.

A autoria, de igual modo, restou inconteste e recai sobre os réus tão somente em relação ao crime de tráfico de drogas.

O policial militar Alessandro Batista da Silva, policial militar, em juízo, disse "o patrulhamento pelo local ocorreu pois tinham notícias de que produtos de furto estavam sendo trocados por drogas na Vila Esperança. Disse que o local é conhecido como ponto de venda de drogas. Informou que com o réu Eduardo estava um tijolo de crack e que com BRUNO localizaram cocaína e crack em uma sacola que tentou dispensar. Disse que os réus são conhecidos dos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico e tinham notícias de que estavam associados. Falou que a "biqueira era do Dudu" e que BRUNO trabalhava com ele. Ressaltou que as denúncias contra os réus eram frequentes".

A testemunha de acusação Valdinei Ribeiro Pereira, policial militar, judicialmente, reprisou a assertiva de seu colega acrescentando "que a abordagem foi feita em uma viela e que os acusados tentaram fugir da abordagem. Disse que o acusado Eduardo

comanda o tráfico de drogas na Vila Esperança, inclusive, a maioria dos vendedores são menores de idade. Falou que a viela é estratégica porque facilitar o deslocamento de fuga. Disse que o acusado Bruno informou que Eduardo tinha estado no local há poucos instantes. O referido réu estava com uma sacola preta contendo crack. Eduardo também estava em posse de uma bicicleta trocada por drogas. Os réus não têm nenhuma ocupação lícita".

O réu Bruno, em seu interrogatório judicial, negou a prática dos fatos que lhe são imputados. Disse "que foi abordado por engano por ter o mesmo biotipo de outro rapaz que correu da abordagem policial. Alegou que não estava com drogas, que tinha saído de casa para comprar leite em um minimercado".

O corréu Eduardo, em seu interrogatório judicial, negou a prática dos fatos que lhe são imputados. Disse "que estava dentro de casa quando os policiais militares ingressaram em sua residência e que conhecia o réu Bruno de vista". Falou que os policiais tentaram incriminá-lo".

Com efeito, a negativa de autoria dos réus não encontra amparo nas demais provas do feito, sendo de rigor a condenação.

In casu, a tipificação do crime de tráfico de drogas extrai-se das circunstâncias da prisão, da quantidade e diversidade de droga apreendida (50 porções de cocaína/crack e 01 porção de maconha), modo pelo qual estava acondicionada- em porções individuais a facilitar a comercialização e disseminação da droga e também do tijolo de droga apreendido. Neste passo, ressalto que a finalidade mercantil com que os réus traziam e guardavam as substâncias entorpecentes restou evidente, pois, a quantidade de drogas apreendidas, por si só, já é suficiente para a caracterização do tráfico ilícito de entorpecentes, sendo, pois, incompatível com o uso momentâneo.

Nesse contexto, a versão dos réus, além de inconsistente e implausível de per si, permaneceu de todo isolada no contexto probatório, já que eles nada produziram, em absoluto, que ao menos desse algum lastro às suas informações, enquanto os depoimentos reproduzidos sob o contraditório encerraram-se convergentes e coesos à confirmação do fato imputado, não se percebendo qualquer mínima evidência que fosse acerca de uma falsa incriminação.

Assim, a mendaz versão dos réus restou ilhada nos autos e foi infirmada pelos relatos dos policiais, que foram absolutamente coerentes e bastaram à comprovação dos fatos, por não haver na hipótese qualquer contradição ou indicio de que tenham faltado com a verdade para incriminar falsamente o réu. Aliás, está desgastada a tese de perseguição, lançada ao léu por muitos e muitos réus, que tentam subverter os policiais em criminosos que pretendem encarcerar cidadão inocentes, como se não tivessem criminosos o bastante para se ocupar. Neste sentido, o voto do eminente Desembargador Souza Nery na Apelação Criminal nº. 990.10.311699-2:

"Aceitar-se a versão do réu seria fechar os olhos a uma realidade manifesta e dar as costas ao óbvio, em total e completo desapego às normas genéricas da verdade e do bom-senso, que emanam sem nenhuma dúvida dos autos. Nada obstante deva estar o julgador sempre atento e dedicado às teses defensórias, verdade é que há um momento em que as versões não podem ser aceitas, pelo óbvio manifesto que representam sua irre realidade. O julgador, então, que é e deve ser homem de bom-senso e com preocupação com a realidade ideal, pode e deve sempre afastar as teses sem qualquer cunho de razoabilidade, como aqui. Dar-se crédito àquele que mantém na sua posse considerável quantidade de droga, em plena e objetiva ação delituosa, em detrimento das palavras de agentes de lei, que cumpriam seu papel de proteger a sociedade, seria inverter de tal forma os valores, que se deixaria em descrédito a própria justiça. Tanto não é possível, exatamente porque as escusas são para livrá-lo da responsabilização, que é imperiosa, todavia. Ou valem as palavras dos Policiais, ou se estará dando crédito maior a quem possui, mantém em depósito e comercializa drogas, em plena ação delituosa. No confronto, portanto, não há como se inverter posições. Na defesa da sociedade e de todos os homens de bem, que querem ver a Polícia e o Judiciário atuando no combate ao crime e nesta nefasta distribuição de drogas" (g.n.)

Desta feita, a negativa de autoria dos réus nada mais revela do que o intuito de não produzir prova contra si mesmo, o que é plenamente lícito, mas insuficiente

para desfigurar a tese acusatória que vem amparada pelo depoimento dos policiais e prova da materialidade.

Nesse passo, cabe ressaltar que o depoimento prestado pelos policiais é, em essência, coerente e harmônico com as provas acostadas aos autos. É de se asseverar que o simples fato da testemunha ouvida ser policial nada significa para que seja desconsiderado seu depoimento ou que este seja recebido com reservas.

Imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais ou agentes públicos em geral, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são eles aptos, como qualquer cidadão, a presar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento somente procede quando decorrente de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não se evidenciou nestes autos.

Ressalte-se, por fim, que a diligência policial a qual culminou com a apreensão do entorpecente, somente ocorreu devido à divergência constante na cor do veículo descrita no documento. Confira-se:

“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade - Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal n. J. 103.338-3/6 - São Paulo 9º Câmara Criminal - Relator: Ubiratan de Arruda - 30.1.2008-V.U.)

Considere-se ainda que, em casos de crimes graves, como o tráfico de entorpecentes, a grande maioria das pessoas evita servir como testemunha, imperando verdadeira lei do silêncio, razão pela qual desprezar os depoimentos policiais nesses casos implicaria consagrar a total impunidade.

Ressalto, ainda, que para caracterização do crime de tráfico de drogas não é indispensável que o agente seja flagrado realizando o comércio de drogas. O tipo penal do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006 é de conteúdo múltiplo e define crime de perigo abstrato. Dessa maneira, basta a conduta de guardar, ter em depósito, trazer consigo a droga, desde que evidenciada a finalidade de entrega a terceiro, para que o crime em questão reste caracterizado. E, no caso, essa finalidade está bem evidenciada, eis que a quantidade de droga apreendida (50 porções de cocaína/crack e 01 porção de maconha) é fator considerável à caracterização do tráfico, tornando-se incabível falar em desclassificação para o crime de posse de drogas. Nesse sentido:

“... não é indispensável a prova efetiva e direta de qualquer ato de comércio clandestino de droga, bastando o conjunto de indícios e presunções que, saliente-se, são claros e convergem contra o acusado, não podendo o juiz desprezar as regras de experiência comum (praesumptiones hominis), ou seja, a ordem normal das coisas, representando aquelas o conhecimento adquirido pela prática e observação do cotidiano.” (TJSP, Apelação n. 0019906-40.2012.8.26.0071, rel. Julio Caio Farto Salles, j. 11/12/2014) (g.n.).

...

“a noção legal de tráfico de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (STF, 1ª T. H.C. nº 69.806/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Diário da Justiça, Seção I, 04/06/1993, p.11.012)

Diversamente, em relação ao crime de associação para o tráfico (art. 35 da lei de Drogas), observo que não há prova acerca do suposto “animus” associativo entre os réus, sendo de rigor a absolvição. Nesse sentido vem ensinando a doutrina: “não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um animus associativo, isto é, um ajuste prévio no sentido da formação de um vínculo associativo de fato, uma verdadeira *societas sceleris*, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime

visado. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria" (Tóxicos, Vicente Greco Filho, Editora Saraiva, 14ª edição, pág. 209/210).

No mesmo sentido a jurisprudência:

"TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROVA BASTANTE - CONDENAÇÃO MANTIDA - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO NÃO CARACTERIZADA - CONDENAÇÃO AFASTADA DE OFÍCIO COM EXTENSÃO AO CO-RÉU - APELAÇÃO DESPROVIDA. Para a existência do crime de tráfico basta a guarda da substância entorpecente, não sendo exigível a prova da efetiva venda da droga, razão pela qual a simples alegação de ser usuário não basta, por si só, para operar a pretendida desclassificação, mormente quando isolada do conjunto probatório, incumbindo ao réu provar que a substância se destinava para exclusivo consumo pessoal. O crime tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/2006 não se configura diante de uma associação meramente eventual, mas apenas quando ela for estável e duradoura, ligada pelo animus associativo dos agentes, formando uma verdadeira *societas sceleris* que não se confunde com a simples co-autoria. Não tendo restado caracterizado que a associação era reiterada, a conduta deve ser considerada mais como uma consequência da ação única que deu origem ao tipo principal que é o tráfico de substância entorpecente. (TJ-PR - ACR: 4866746 PR 0486674-6, Relator: Rogério Coelho, Data de Julgamento: 18/09/2008, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 7743)."

Por fim, no que tange aos argumentos Defensivos, no sentido de que não há provas suficientes para a condenação, são eles precários, insubsistentes e revelam-se desamparados ante o quadro acusatório firmemente consolidado nos autos. Em verdade, a simples alegação de ausência de provas não é suficiente para afastar a responsabilidade imputada, carecendo de um mínimo qualquer de credibilidade a autodefesa, destituída que foi e é de qualquer alicerce. Ademais, não demonstrou vício no flagrante e no resultado da persecução.

Diante do exposto, por esses fundamentos e mais o que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal e, em consequência, CONDENO os réus BRUNO BRAZ JOVENIL e EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA VALENTIM, já qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da lei 11.343/06. Por fim, ABSOLVO os réus BRUNO BRAZ JOVENIL e EDUARDO HENRIQUE DE SOUZA VALENTIM, da imputação que lhes foi feita como incursos no art. 35, "caput", da lei 11.343/06, o que faço com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Resta dosar a pena de acordo com o critério trifásico adotado pelo Código Penal.

Primeiramente, em relação ao réu Bruno, em observância ao artigo 42 da Lei de Drogas, bem como aos elementos preconizados pelo artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes (F.A. e certidões a fls. 301/303 e 306/314) e, tendo já cumprido pena privativa de liberdade, voltou a delinquir. Isso mostra que tem conduta social reprovável e personalidade voltada à delinquência, já que a mais grave das penas ordinariamente previstas em nossa legislação penal não o intimidou a praticar novo delito. Assim, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase de dosimetria, não estão presentes quaisquer das circunstâncias agravantes e/ou atenuantes. Por fim, na terceira fase, entendo que inexistem causas de aumento ou de diminuição da pena. Não incide a benesse prevista no §4º do artigo 33 da Lei de Drogas, pois o réu não preenche todos os predicados legalmente previstos, pois, além dos maus antecedentes, a quantidade de droga apreendida (49 porções de cocaína-crack) revelam que se dedica à atividade criminosa. Nesse sentido: "Não há ilegalidade na negativa de aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, porquanto a quantidade e a natureza da substância apreendida levaram à conclusão de que o paciente se dedica a atividades delituosas, ou seja, não se trata de traficante ocasional" (HC 297447/RS, Ministro JORGE MUSSI, DJe 13/11/2014). E nem se alegue possível bis in idem relativo ao aumento da pena pelos maus antecedentes e a não aplicação do aludido redutor, uma vez que este deixou de incidir também em virtude da dedicação às práticas delitivas, tudo em fases distintas da dosimetria. Confira-

se: "A valoração da reincidência na segunda etapa da dosimetria, como circunstância agravante, não é incompatível com a sua utilização, na terceira fase, para afastar a incidência da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, porquanto o referido instituto jurídico é sopesado com finalidades distintas em cada fase de fixação da pena, justamente para se alcançar a justa e correta reprimenda necessária para a reprovação e prevenção do delito perpetrado. Precedentes" (HC 214069/SP – Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ - Sexta Turma - DJe 29/11/2013). Desta forma, fixo em definitivo a pena a cumprir de 05 (CINCO) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 583 (QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS) DIAS-MULTA, COM O DIA UNITÁRIO NO PISO MÍNIMO LEGAL.

A pena imposta ao réu deverá ter seu início de cumprimento em regime FECHADO. Apesar de o STF já ter decidido, em sede de controle difuso, pela inconstitucionalidade da regra que determina a obrigatoriedade de adoção de regime inicial fechado para os crimes hediondos e equiparados (Lei 8.072/90, art. 2º, §1º), o citado precedente não concluiu, por outro lado, pela imposição indiscriminada de regime mais brando para o cumprimento inicial da pena em tais delitos. Ao contrário. Ainda que, de fato, não possa a lei vedar, aprioristicamente, a adoção de um regime inicial diverso do fechado, mesmo para os crimes hediondos e equiparados, o STF permitiu a adoção de regime inicial mais severo quando presentes elementos concretos e individualizados, aptos a demonstrar a necessidade de maior rigor da medida privativa de liberdade do indivíduo, nos termos do § 3º do art. 33, c/c o art. 59 do Código Penal (cf. HC 111.840, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 17/12/2013). O caso dos autos, no qual se constatou a prática de tráfico de considerável quantidade de entorpecente, demanda a adoção de regime prisional mais severo, sob pena de se produzir, como efeito colateral de um arrefecimento despropositado da reprimenda estatal, uma sensação de impunidade àqueles que demonstram desprezo à manutenção da ordem pública.

É importante não perder de vista que a consideração do tempo de prisão provisória do réu não altera o panorama do regime inicial da pena aplicada (preso desde 03/03/2022-fls. 182/183). Assim, deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do Código de Processo Penal, pois como bem indica Guilherme de Souza Nucci, "O disposto no §2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração ao escolher o regime inicial do réu no caso de condenação. Não significa de modo algum que o magistrado deve sempre conceder o regime inicial mais brando, pois se pode considerar como adequado regime inicial mais gravoso, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3º. Afinal, somente o juiz da execução penal possui o quadro completo das condenações daquele réu, do seu comportamento carcerário, e do seu merecimento" ("Código de Processo Penal Comentado", 13ª edição, Editora Forense, páginas 805 e 806). Desta forma, melhor que a questão seja analisada pelo Juízo de Execuções Criminais, que certamente disporá de elementos mais substanciais para decidí-la. Inviável a substituição por pena restritiva de direitos, seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos previstos nos artigos 44, III, e 77, II, ambos do Código Penal, seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, seja, finalmente, porque o art. 44, caput, da Lei nº 11.343/2006, são expressos ao proibir referido benefício. Filio-me ao entendimento que sustenta a constitucionalidade de tais dispositivos, pelas seguintes razões, algumas delas retiradas da Arguição de Inconstitucionalidade no HC 120.353-SP, julgada em 04.11.2009 pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, Rel. originário Min. Og Fernandes, Rel. para acórdão Min. Ari Pargendler: i) o art. 5º, inciso XLVI, da CF/88, determina que a lei regulará a individualização da pena; ii) o art. 5º, inciso XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão, destacando também a importância da repressão a esse delito no art. 5º, inciso LI, o qual autoriza a extradição de brasileiro naturalizado comprovadamente envolvido com tráfico de drogas; iii) é perfeitamente possível que o legislador ordinário proíba a substituição da pena por restritiva de direitos, tanto que o art. 44, do CP, veda o benefício para todos os crimes praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa ou com pena superior a 04



anos, ou, ainda, no caso de ser o agente reincidente em crime doloso; iv) o Brasil assinou tratados internacionais se comprometendo a combater o tráfico de drogas; v) o crime de tráfico de drogas, além de ser equiparado a hediondo e ser a principal causa de inúmeros outros delitos patrimoniais, gera efeitos nefastos para a sociedade e para as famílias de bem, de modo que a concessão do benefício, além de ser, no meu entender, incompatível com a sua gravidade, não se mostraria suficiente para a prevenção ou reprovação do delito (CP, art. 59, in fine), gerando ofensa ao disposto no art. 44, III, do CP, além de verdadeira sensação de impunidade nesta interiorana cidade de Avaré.

Deixo de reconhecer o direito do réu de apelar em liberdade, em observância ao artigo 312 do CPP c.c. artigo 2º, § 3º da Lei nº 8.072/90, pois a gravidade do delito, que vem se alastrando de forma avassaladora também nas pequenas cidades, torna evidente a necessidade da prisão para se garantir a ordem pública. Ademais, o réu foi preso preventivamente e permaneceu recolhido por todo o processo e não seria razoável, agora que foi condenado, ser colocado em liberdade, ainda que diante do regime imposto pela lei e do fato de ter praticado conduta de extrema gravidade, que deve ser exemplarmente punida. Recomende-se.

Vertente ao corrêu Eduardo Henrique, atento aos elementos preconizados pelo artigo 42 da Lei 11.343/06 c.c. 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário (F.A. e certidões a fls. 304/305 e 315/316), razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, ante a falta de elementos sobre a real situação econômica do réu (CP, arts. 49 e 60). Na segunda fase, não estão presentes nenhuma das circunstâncias agravantes e/ou atenuantes. Na terceira fase, entendo que se faz necessário o reconhecimento da diminuição prevista no § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, pois o réu é primário e não há nos autos notícias de sua participação em associação criminosa. Assim, diminuo a pena anteriormente imposta em 2/3 (dois terços) resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Não estão presentes mais causas de aumento ou de diminuição da pena. Portanto, fixo em definitivo a pena a cumprir de 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO e PAGAMENTO DE 166 (cento e sessenta e seis) DIAS-MULTA, com o dia unitário no piso mínimo legal.

Pese contrário ao entendimento deste Magistrado, necessário apontar que o regime inicial deverá ser o ABERTO, conforme recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exarado no bojo do HC n. 596603-SP, no qual houve determinação para imposição de regime inicial aberto para cumprimento de pena, inclusive em relação a fatos futuros, na hipótese de condenação por tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §2º, do Código Penal. Confira-se (...) Aos condenados que atualmente cumprem pena e aos que vierem a ser sancionados por prática do crime de tráfico privilegiado, determinar que não se imponha - devendo haver pronta correção aos já sentenciados - o regime inicial fechado de cumprimento da pena. (STJ - HC: 596603 SP 2020/0170612-1, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, j. 04/08/2020). Tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal - HC 118.533 - reconheceu que o delito em questão não é mais hediondo, entendo viável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Desta forma, faço a substituição da pena privativa de liberdade anteriormente fixada por duas restritivas de direitos. Assim sendo, observado o disposto pelo artigo 44, parágrafo 2º, 2ª parte e na forma dos artigos 45, parágrafo 1º e 46, todos do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, quais sejam, a de Prestações de Serviços à Comunidade e de Prestação Pecuniária, por se revelarem as mais adequadas ao caso, sendo aquela consistente em tarefas gratuitas a serem desenvolvidas, pelo prazo da condenação, junto a entidade determinada pelo juízo da execução, devendo ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, que será distribuída e fiscalizada, de modo a não prejudicar a jornada de trabalho do condenado, sem prejuízo da multa já fixada e a prestação pecuniária no valor de um terço do salário mínimo nacional da época da infração penal, sendo destinada para entidade beneficente também indicada pelo juízo das execuções penais.

Ao Juízo da Execução, após o trânsito em julgado desta decisão, caberá fiscalizar a entidade beneficiada com a prestação de serviços, a qual deverá ser comunicada a respeito, através de seu Representante, com remessa de cópia da presente sentença, incumbindo-lhe encaminhar mensalmente relatório circunstanciado, bem como a qualquer tempo, comunicar sobre a ausência ou falta disciplinar da condenada, consoante disposto pelo artigo 150 da Lei nº 7.210/84. Deverá, ainda, ser cientificado que a condenada é facultada cumprir a pena substitutiva em menor tempo (artigo 55, do Código Penal), sendo que, nunca inferior à metade da pena privativa de liberdade fixada ou restante.

De acordo com o artigo 387, parágrafo único do CPP, REVOGO a prisão preventiva decretada a fls. 128/132, podendo o réu Eduardo recorrer em liberdade. Expeça-se alvará de soltura.

Conforme art. 63 da Lei nº 11.343/06 c/c art. 91 do CP, decreto o perdimento de tudo quanto apreendido neste processo. Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade da substância entorpecente ou sobre a regularidade do laudo respectivo, fica determinado, desde já, sua destruição por incineração, na forma da legislação vigente (Lei n. 11.343/06, arts. 33, §§ 1º e 2º, e 58, §1º), no prazo máximo de 30 (trinta) dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se à autoridade de polícia judiciária competente, caso isso ainda não tenha sido providenciado.

Registre-se, desde logo, que, em caso de recebimento de eventual recurso de apelação interposto contra a presente, deverá ser expedida a competente guia de execução provisória em nome dos réus/condenados recorrentes, nos termos do que dispõe o art. 9 da Resolução nº 113/2010 – CNJ, para que possa, quando for o caso, obter os benefícios previstos na LEP (sumula do STF, Enunciado nº 716).

Oportunamente, após o trânsito em julgado da presente, adotem-se as seguintes providências: (a) expeça-se guia de execução (definitiva, se o caso) dos condenados; (b) proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686, do Código de Processo Penal; (c) oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando as condenações, com as devidas identificações, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto no art. 15, III, da Constituição da República c/c o art. 71, §2º, do Código Eleitoral; (d) oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; (e) efetuem-se as averbações de praxe (NSCGJ, Cap. V, itens 22, d, e 23). Custas processuais nos termos da lei.

P.I.C.

Avare, 04 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA